

刑法
No.78

共通問題 R4-16

(配点: 2)

月	日
月	日

違法性に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

- ア. 私人が現行犯人を逮捕しようとする場合、犯人から抵抗を受けたときは、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使したことで犯人に傷害を負わせたとしても、法令による行為に当たるから、傷害罪が成立することはない。
- イ. 勤労者の争議行為に際し、人の看守する建造物に看守者の意思に反して侵入した場合、法令による行為に当たるから、建造物侵入罪が成立することはない。
- ウ. 虚偽告訴の罪で起訴された者が、人違いで告訴したと気づきながら、公判廷において、公然と虚偽の事実を摘示して被告訴人の名誉を毀損した場合、被告人としての防御権の行使に当たるから、名誉毀損罪が成立することはない。
- エ. 商人が、自己と通謀して客を装い他の客の購買心をそそる者（いわゆる「さくら」）を使って、商品の効用が極めて大きく世評も売れ行きも良いように見せかけて客を欺罔し、これを信じた客に効用の乏しい商品売り付けた場合、正当な業務による行為に当たるから、詐欺罪が成立することはない。
- オ. 宗教上の加持祈祷の行として他人の生命、身体に危害を及ぼす有形力を行使し、その結果、その他人を死亡させた場合、正当な業務による行為に当たるから、傷害致死罪が成立することはない。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

No.78	違法性	正答率
共通R4-16	正解 1	85%

ア 正しい

最判昭 50.4.3. 判例は、「現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の實力を行使することが許され、たとえその實力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法 35 条により罰せられない」としている。

イ 誤っている

最大判昭 48.4.25 (百選 I 16 事件)。判例は、「勤労者の組織的集団行動としての争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について刑法上の違法性阻却事由の有無を判断するにあつては、……当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを判定しなければならない」としている。したがって、勤労者の争議行為に際し、人の看守する建造物に看守者の意思に反して侵入した場合、建造物侵入罪が成立することはある。

ウ 誤っている

最判昭 27.3.7. 判例は、被告人が A に対して詐欺の告訴をしたのは人違いであったことに気付いていながら、公判廷において、真意に反して欺罔の主張をし公然虚偽の事実を摘示して死者である A の名誉を毀損したという事案において、被告人としての防禦権の範囲を逸脱したもの、被告人の防禦権の濫用と認めるべきであるとして、名誉毀損罪の成立を認めている。

エ 誤っている

大判昭 6.11.26 は、顧客の面前において物品の効用に付き自ら実験をするにとどまらず、いわゆる「さくら」を用いる方法により、商品の効用が極めて大きいのみならず世評も売れ行きも共に良好で各方面より注文がある旨の虚構の事実を示して顧客を欺罔し、よってその買受けの決意をさせた場合、商人としての業務上正当の行為に属するものとはいえず、詐欺罪と構成するとしている。

オ 誤っている

最大判昭 38.5.15. 判例は、本記述と同様の事案において、「被告人の本件行為は、……一種の宗教行為となされたものであつたとしても、それが……他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、これにより被害者を死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであつて、憲法 20 条 1 項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはなく、これを刑法 205 条に該当するものとして処罰したことは、何ら憲法の右条項に反するものではない」としている。その理由として、判例は、「被告人の右加持祈祷行為の動機、手段、方法およびそれによつて右被害者の生命を奪うに至つた暴行の程度等は、医療上一般に承認された精神異常者に対する治療行為とは到底認め得ない」ということを挙げている。したがって、宗教上の加持祈祷の行として他人の生命、身体に危害を及ぼす有形力を行使し、その結果、その他人を死亡させた場合、傷害致死罪が成立することはある。

以上により、正しい記述はアの 1 個であり、したがって、正解は肢 1 となる。